

1500388-47.2021.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... apreensão de anotações e petrechos típicos do tráfico, como balanças de precisão. Com efeito, não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar um inocente. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500388-47.2021.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500388-47.2021.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290749/2021 - DEL.POL.CONCHAL, 21014268 - DEL.POL.CONCHAL, 1337/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2290749 -

DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Vistos.

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 13 e 26, e IGOR FERNANDO MACIEL FERRARI, qualificado às fls. 13 e 30, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos artigos 35, caput, e artigo 33, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque (i) em data inicial ainda não determinada, mas que perdurou até o dia 25 de outubro de 2021, na rua Vicente Vigano, 72, nesta cidade e comarca de Conchal, associaram-se, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; bem como (ii) guardavam e tinham em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 50 (cinquenta) pinos de cocaína, bem como 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, pesando,

respectivamente, 37,5 g (trinta e sete gramas e cinco decigramas) e 78,7 g (setenta e oito gramas e sete decigramas).
Notificados às fls. 86 e 88, os acusados apresentaram defesa prévia às fls. 92/97 e 102/105.

A denúncia foi recebida em 10 de março de 2022 (fls. 114/118).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

A d. Representante do Ministério Público manifestou-se oralmente, conforme gravação audiovisual.

A i. Defesa de Pedro reiterou os termos da defesa prévia, requerendo a absolvição do acusado, quer quanto à prática do tráfico, quer quanto ao crime de associação.

A i, defesa de Igor, por sua vez, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, CPP.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/12, auto de exibição e apreensão (fls. 17/19), laudo de constatação de fls. 28/29, indicador de que os acusados guardavam e tinham em depósito 50 (cinquenta) porções de cocaína, com massa de 37,5g (trinta e sete gramas e cinco decigramas) e 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, com massa de 78,7g (setenta e oito gramas e sete decigramas). Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 131/133, está comprovado que a substância apreendida com o acusado era "COCAÍNA, substância relacionada na Lista F1 das substâncias de uso proscrito no Brasil" e "tetrahydrocannabinol (THC), constante na Lista F2".

Posto isso, de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Ouvida em juízo, a testemunha Eric de Oliveira Mota disse que recebeu denúncia anônima de que os acusados estariam ocultando entorpecentes na residência em que compartilhavam. Igor já era conhecido dos meios policiais. Foram ao endereço, onde encontraram Igor em frente a residência. Ao avistar a viatura, Igor demonstrou nervosismo e correu para dentro do imóvel. Da parte externa, foi possível visualizar porções de drogas fracionadas e preparadas para o comércio. No interior, localizaram no banheiro, várias porções de cocaína e maconha, além de uma sacola contendo cocaína, três balanças de prisão, um caderno com anotações de contabilidade do tráfico, petrechos para o embalo das drogas e quantia em dinheiro. À acusação, confirmou que a denúncia mencionava os nomes dos dois réus. Às perguntas da Defesa, respondeu que foi a primeira notícia envolvendo o nome dos dois acusados em conjunto.

No mesmo sentido o depoimento judicial da testemunha guarda municipal Ivan Aparecido, que relatou o recebimento de denúncia anônima envolvendo os dois acusados, de que estariam armazenando e preparando entorpecentes para a venda. Ao chegar no local, o acusado Igor avistou a viatura, ficou nervoso e ingressou no imóvel. Da parte externa, foi possível visualizar que havia entorpecentes no interior da residência. Ingressaram e localizaram mais entorpecentes nos banheiros. Também encontraram petrechos e dinheiro em espécie. Às perguntas da Defesa, respondeu que não conhecia Pedro.

Interrogado em juízo, Pedro Rodrigues de Oliveira disse que, junto com Igor, são

usuários de drogas e estavam devendo para um traficante. Disse que o traficante os ameaçou de morte caso não guardassem o entorpecente.

Interrogado em juízo, Igor Fernando Maciel Ferrari disse que pegou drogas fiado com o traficante. Ficou sem emprego e não tinha como pagar a dívida. O traficante os ameaçou de morte, exigindo pagamento. Alternativamente, ofereceu que guardassem a droga para quitar a dívida. Às perguntas da Defesa, respondeu que havia três dias que recebeu as drogas. Às perguntas do juízo, respondeu que devia R\$1.000,00 (mil reais) para o traficante, mas não soube precisar o quanto corresponde em drogas.

Diante da prova oral produzida, tenho que a versão exclupatória apresentada pelos réus, de que são apenas usuários de entorpecentes e guardavam a droga, em razão de ameaças de morte não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos. A mudança da narrativa, com divergência entre o que simplesmente afirmaram em solo policial, sem qualquer menção a suposta dívida, e o que declarara, em juízo, infirmam sua defesa. Não bastasse, Igor alegou que não sabia o que havia dentro de suposta mochila preta, o que se contradiz pelo modo de armazenamento das drogas, bem como pelos petrechos encontrados no local, como balanças de precisão e anotações de contabilidade, que expressamente mencionam "kits de drogas" (fls. 37/39).

Ao passo que as palavras dos agentes de segurança, servidores públicos ouvidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e estão em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, indicando que a destinação da droga apreendida, tendo em vista a variedade e a forma de acondicionamento, se destinava à entrega e ao consumo de terceiros, o que caracteriza o tráfico.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados por policiais, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial.

Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846)."

Ademais, os relatos estão amparados pela apreensão material da droga, fracionada em porções típicas do comércio ilegal, além de quantidade significativa de cocaína que ainda seria fracionada e preparada. Houve ainda apreensão de anotações e petrechos típicos do tráfico, como balanças de precisão. Com efeito, não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar um inocente. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material. (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014)."

Nesse contexto, afastado a pretensão de desclassificação para o delito do artigo 28, LD. Mesmo que o réu também fosse usuário de entorpecentes, tal fato não elide a traficância a ele atribuída, porquanto não são raros os casos de usuários que também se dedicam ao tráfico, como forma de manter o próprio vício e de conseguir dinheiro sem esforço, pelo que não prospera a solução desclassificatória.

Por fim, tenho que não demonstrada o vínculo associativo a caracterizar o delito de associação para o tráfico, visto que sequer descrito circunstanciadamente na denúncia, razão pela qual, impõe-se a parcial procedência do pedido condenatório. Certa, pois, a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, resta, enfim, a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que os isentem de sanção.

Passo à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06.

Quanto ao réu Pedro Rodrigues de Oliveura.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu deve ser considerado tecnicamente primário (fls. 65/66), à míngua de informações a respeito do delito referido em audiência. As demais circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. Assim, mantenho a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, inexistem causas de aumento. Por outro lado, aplico o redutor inscrito no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O réu é tecnicamente primário e não há provas de que integra, de fato, organização criminosa. Entretanto, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas com o acusado, mormente a meia centena de porções de cocaína ainda não fracionada, tenho que as margens legais do redutor previsto no artigo 33, §4º, LD devem ser adequadamente sopesadas, tendo em vista o elevado potencial danoso da conduta do acusado, com grande quantidade de drogas, com notório poder viciante e consequências severas aos seus usuários. A respeito da possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria da pena, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena." (HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022). Portanto, a pena deve ser reduzida em 1/2 (metade), definindo a pena final em terceira fase em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

À míngua de outros elementos, é de rigor a fixação do mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato.

A Resolução nº 5/12 do Senado Federal suspendeu a execução do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na parte em que vedava a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Nessa medida, verifico a possibilidade da aplicação do artigo 44 do Código Penal, nos termos dos incisos II e III, pois a culpabilidade e os antecedentes, bem como as circunstâncias do delito indicam que a substituição é suficiente ao réu.

Faz jus, portanto, à substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas penas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: a prestação de serviços à comunidade ou à entidade cadastrada pelo Juízo, pelo prazo da pena cominada, e a limitação de fim de semana, nas condições a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em caso de descumprimento da pena substituída, fixo o regime inicial aberto.

Quanto ao réu Igor Fernando Maciel Ferrari.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu é tecnicamente primário (fls. 64). As demais circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Assim, mantenho a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, inexistem causas de aumento. Por outro lado, aplico o redutor inscrito no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O réu é tecnicamente primário e não há provas de que integra, de fato, organização criminosa. Entretanto, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas com o acusado, mormente a meia centena de porções de cocaína ainda não fracionada, tenho que as margens legais do redutor previsto no artigo 33, §4º, LD devem ser adequadamente sopesadas, tendo em vista o elevado potencial danoso da conduta do acusado, com grande quantidade de drogas, com notório poder viciante e consequências severas aos seus usuários. A respeito da possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria da pena, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena." (HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022). Portanto, a pena deve ser reduzida em 1/2 (metade), definindo a pena final em terceira fase em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

À míngua de outros elementos, é de rigor a fixação do mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato.

A Resolução nº 5/12 do Senado Federal suspendeu a execução do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na parte em que vedava a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Nessa medida, verifico a possibilidade da aplicação do artigo 44 do Código Penal, nos termos dos incisos II e III, pois a culpabilidade e os antecedentes, bem como as circunstâncias do delito indicam que a substituição é suficiente ao réu.

Faz jus, portanto, à substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas penas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: a prestação de serviços à comunidade ou à entidade cadastrada pelo Juízo, pelo prazo da pena cominada, e a limitação de fim de semana, nas condições a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em caso de descumprimento da pena substituída, fixo o regime inicial aberto.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público contida na denúncia para CONDENAR:

(i) PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 13 e 26, como incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo previsto na pena substituída e limitação de fim de semana, sendo que o local e modo de cumprimento serão indicados pelo D. Juízo das Execuções; absolvendo-o, contudo, da imputação como incurso no artigo 35, LD, com fundamento no artigo 386, inciso VII, CPP;

(ii) IGOR FERNANDO MACIEL FERRARI, qualificado às fls. 13 e 30, como incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo previsto na pena substituída e limitação de fim de semana, sendo que o local e modo de cumprimento serão indicados pelo D. Juízo das Execuções; absolvendo-o, contudo, da imputação como incurso no artigo 35, LD, com fundamento no artigo 386, inciso VII, CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100(cem) Ufesps, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Encerrada a instrução e substituída a pena corporal por restritiva de direitos, concedo aos réus o direito de aguardar o trânsito em julgado para dar início ao cumprimento das penas. Expeçam-se os alvarás de soltura clausulados.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade(art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) expeçam-se as certidões aos d. Patronos nomeados, nos termos do Convênio OAB/DPESP.

7) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados. P.I.C. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Conchal, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA